précis DOMAT DROIT PRIVÉ

Alain BÉNABENT

DROIT DE LA FAMILLE

5e édition

LGDJ un savoir-faire de Lextenso

DROIT DE LA FAMILLE

5e édition

À jour au 9 septembre 2020

ALAIN BÉNABENT
Professeur agrégé des Facultés de droit, avocat aux Conseils

LGDJ un savoir-faire de Lextenso

© 2020, LGDJ, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
www.lgdj-editions.fr
ISBN 978-2-275-07387-3

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

AJ fam.	Actualité juridique droit de la famille (Dalloz)
Cass. ass. plén.	Assemblée plénière de la Cour de cassation
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)
C. civ.	Code civil
C.M.	Chambre mixte
CE	Conseil d'État
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
Cass. 1re civ., 2e, 3e	Chambres civiles de la Cour de cassation
Cass. com.	Chambre commerciale de la Cour de cassation
Cons. const.	Conseil constitutionnel
CPC	Code de procédure civile
CPI	Code de la propriété intellectuelle
Cass. crim.	Chambre criminelle de la Cour de cassation
D. ; DP	Dalloz recueil ; Dalloz périodique
Defrénois	Répertoire du notariat
Dr. fam.	Droit de la famille (Revue LexisNexis)
Dr. soc.	Droit social
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
JCP	Juris-classeur périodique (semaine juridique)
Loy. et copté	Loyers et copropriété (Revue LexisNexis)
LPA	Les Petites Affiches
Mél.	Mélanges
RDC	Revue des contrats
Cass. req.	Chambre des requêtes de la Cour de cassation
RIDC	Revue internationale de droit comparé
Rev. sc. crim.	Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
RJPF	Revue juridique personnes et famille
RLDC	Revue Lamy Droit civil
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil
Cass. soc.	Chambre sociale de la Cour de cassation
TGI	Tribunal de grande instance
Trib. civ.	Tribunal civil

SOMMAIRE

Introduction 15
§ 1. Le lien familial 16
§ 2. Le cercle familial 20
§ 3. Le droit familial 24
§ 4. La juridiction familiale 28

PREMIÈRE PARTIE. L'ALLIANCE 31

SOUS-PARTIE 1. LE MARIAGE CIVIL 35

Titre 1. L'acte de formation du mariage civil 39

Chapitre 1. Conditions d'ordre social 43

Section 1. L'ex-prohibition du mariage homosexuel 43

Section 2. La prohibition de la polygamie 46

Section 3. La prohibition du mariage incestueux 48
§ 1. Les cas d'empêchement 50
§ 2. Sanctions et dispenses 51

Chapitre 2. Les conditions individuelles 53

Section 1. Conditions physiques 53
§ 1. Conditions tenant à l'âge 53
§ 2. Conditions tenant au sexe 54
§ 3. Conditions tenant à l'état de santé 55

Section 2. Conditions de capacité 57
§ 1. Mineurs 58
§ 2. Incapables majeurs 60

Section 3. Conditions de consentement 60

§ 1. Le consentement au mariage 61
§ 2. L'intention matrimoniale 68

Chapitre 3. Le formalisme du mariage 73

Section 1. Les mariages célébrés en France 74
§ 1. Les formalités préparatoires 74
§ 2. Les oppositions à la célébration 77
§ 3. La célébration du mariage 81
§ 4. La preuve du mariage 84

Section 2. Les mariages célébrés à l'étranger 86
§ 1. Mariages concernant un Français 86
§ 2. Mariages entre étrangers 89

Chapitre 4. La nullité du mariage 95

Section 1. L'action en nullité 95

Section 2. Les effets de la nullité 99

Titre 2. L'état de mariage : les effets du mariage civil 105

Chapitre 1. Le statut individuel de chaque époux 107

Section 1. Effets du mariage sur le statut personnel 107

Section 2. Le maintien de la liberté individuelle 110
§ 1. Les attributs relatifs à l'intégrité de la personne 111
§ 2. Les attributs relatifs au comportement de la personne 113

Chapitre 2. Les liens personnels entre époux 117

Section 1. Les droits et devoirs réciproques des époux 118
§ 1. Le devoir de respect 120
§ 2. Le devoir de communauté de vie 122
§ 3. Le devoir de fidélité 127
§ 4. Le devoir d'assistance 130

Section 2. La fonction commune 130

Chapitre 3. Les effets sur le plan patrimonial 133

Section 1. Le statut matrimonial impératif 133
§ 1. L'autonomie de chaque époux 134
§ 2. La sauvegarde des intérêts familiaux 139

Section 2. Le régime matrimonial 147
§ 1. Les régimes de type séparatiste 148
§ 2. Les régimes de type communautaire 149

Titre 3. Le relâchement du mariage : les séparations 153
Chapitre 1. Les séparations spontanées 155
Section 1. Origines de la séparation de fait 156
Section 2. Effets de la séparation de fait 157
Section 3. Issue de la séparation de fait 158
Chapitre 2. Les séparations judiciairement organisées 159
Section 1. La séparation de corps 159
§ 1. Prononcé de la séparation de corps 160
§ 2. Les effets de la séparation de corps 161
§ 3. La fin de la séparation de corps 164
Section 2. Les séparations organisées autour d'une instance en divorce 169
Titre 4. La dissolution du mariage 173
Sous-titre 1. Le veuvage 175
Chapitre 1. Le veuvage par décès 177
Section 1. Effets d'ordre personnel 177
Section 2. Effets d'ordre patrimonial 179
§ 1. Dissolution du régime matrimonial 180
§ 2. Droits successoraux du conjoint survivant 180
§ 3. Droits alimentaires 185
Chapitre 2. Le quasi-veuvage par absence déclarée 187
Sous-titre 2. Le divorce 191
Chapitre 1. La question du divorce 193
Section 1. Historique 195
Section 2. Tableau général 202
Chapitre 2. Les voies d'accès au divorce 207
Section 1. Le divorce contractuel 209
§ 1. Le divorce contractuel sans juge 211
§ 2. Le divorce contractuel soumis à homologation judiciaire 214
Section 2. Le divorce judiciaire 217
Sous-section 1. Les cas de divorce contentieux 217
§ 1. Le divorce accepté en son principe 217
§ 2. Le divorce par altération définitive du lien conjugal 220

§ 3. Le divorce pour faute 223
§ 4. Les griefs conjugaux 225
§ 5. Les faits neutralisants 229
§ 6. Le partage des torts 233
Sous-section 2. La procédure des divorces contentieux 234
§ 1. La phase préparatoire 236
§ 2. La phase du jugement 242
Chapitre 3. Les conséquences du divorce 253
Section 1. Les effets d'ordre personnel 253
§ 1. Les effets relatifs à la personne des époux 255
§ 2. Les conséquences du divorce à l'égard des enfants 258
Section 2. L'apurement patrimonial 259
§ 1. La liquidation patrimoniale 260
§ 2. Le sort du logement familial 269
§ 3. Les dommages-intérêts 274
Section 3. La prestation compensatoire 275
§ 1. Droit à prestation 277
§ 2. Régime procédural 278
§ 3. Fixation de la prestation 280
§ 4. Modalités de la prestation 287
§ 5. Paiement de la prestation 293
SOUS-PARTIE 2. LA QUASI-ALLIANCE 295
Titre 1. Le PACS 297
Chapitre 1. La formation du PACS 303
Section 1. Les conditions du PACS 303
§ 1. Capacité 304
§ 2. Consentement 305
§ 3. Contenu 305
Section 2. Le formalisme du PACS 307
§ 1. Phase préparatoire 311
§ 2. Phase solennelle 311
§ 3. Phase de publicité 313
Section 3. La modification du PACS 313
Chapitre 2. Les effets du PACS 315

Section 1. Les effets d'ordre personnel 316
§ 1. Obligations réciproques 316
§ 2. Absence d'effets envers les tiers 317
Section 2. Les effets d'ordre patrimonial 318
§ 1. Le statut de base 318
§ 2. Le patrimoine 321
Chapitre 3. La dissolution du PACS 325
Section 1. Les cas de dissolution 327
§ 1. Cas analogues au mariage 327
§ 2. Cas spécifiques au PACS 328
§ 3. Séparation de fait 331
Section 2. Conséquences de la dissolution 331
Titre 2. Le concubinage (ou union libre) 335
Chapitre 1. La situation pendant le concubinage 339
Chapitre 2. La situation à la fin du concubinage 343

DEUXIÈME PARTIE. LA DESCENDANCE 347
SOUS-PARTIE 1. LE DROIT DE LA FILIATION 349
Titre 1. Les données de base 351
Section 1. Le lien de filiation 351
Section 2. L'architecture classique du droit de la filiation 352
Section 3. La double révolution du XXIe siècle 354
§ 1. La révolution des droits de l'homme 354
§ 2. La révolution médico-scientifique 355
Section 4. Le régime particulier des actions d'état 357
§ 1. Nécessité d'une action en justice 359
§ 2. Caractères des actions relatives à la filiation 359
§ 3. Règles de procédure 361
§ 4. Règles de preuve 363
Titre 2. La filiation spontanée 367
Chapitre 1. L'établissement de la filiation 369
Section 1. L'établissement de la maternité 371
§ 1. L'acte de naissance 371
§ 2. La reconnaissance de maternité 372

§ 3. La possession d'état judiciairement constatée 377
§ 4. L'action en recherche de maternité 381

Section 2. L'établissement de la paternité 383
§ 1. La présomption de paternité du mari 383
§ 2. La reconnaissance de paternité 387
§ 3. La possession d'état judiciairement constatée 387
§ 4. L'action en recherche de paternité 388

Chapitre 2. Preuve et effets de la filiation établie 389

Section 1. La preuve de la filiation 389

Section 2. Effets de la filiation établie 390

Chapitre 3. La contestation de la filiation établie 393

Section 1. Ouverture de l'action 394
§ 1. Réunion d'un titre et d'une possession d'état 395
§ 2. Présence d'un seul de ces éléments 396

Section 2. Régime de l'action 397

Titre 3. La filiation médicalement assistée 401

Chapitre 1. L'organisation des techniques permises 403

Section 1. Principes directeurs communs 403

Section 2. La procréation artificielle endogène 406

Section 3. La procréation artificielle exogène 407
§ 1. La procréation à demi exogène 408
§ 2. La procréation entièrement exogène : le don d'embryon 410

Chapitre 2. Les techniques interdites 413

Section 1. Les prohibitions du droit français 413
§ 1. Le recours à des « mères porteuses » 413
§ 2. Le clonage 415

Section 2. Les effets d'une pratique prohibée 415

Titre 4. La filiation élective : l'adoption 419

Chapitre 1. L'adoption plénière 421

Section 1. Conditions 422
§ 1. Conditions relatives à l'adoptant 422
§ 2. Conditions relatives à l'adopté 424
§ 3. Conditions relatives au rapport adoptant-adopté 429

Section 2. Procédure de l'adoption plénière 429
Section 3. Effets de l'adoption plénière 432
Chapitre 2. L'adoption simple 435
Section 1. Les conditions de l'adoption simple 435
Section 2. Effets de l'adoption simple 437
Section 3. Révocation de l'adoption simple 441
Chapitre 3. L'adoption internationale 443
SOUS-PARTIE 2. LE DROIT DE L'ÉDUCATION 447
Titre 1. Le gouvernement de l'enfant : l'autorité parentale 449
Chapitre 1. La dévolution de l'autorité parentale 467
Section 1. Titulaires du droit d'autorité parentale 468
§ 1. Dévolution initiale 468
§ 2. Changements ultérieurs 469
§ 3. Retrait de l'autorité parentale 469
§ 4. La fin de l'autorité parentale 473
Section 2. Titulaires de l'exercice de l'autorité parentale 475
Sous-section 1. Les variétés possibles 475
§ 1. L'exercice conjoint de l'autorité parentale 475
§ 2. L'exercice exclusif de l'autorité parentale 478
§ 3. L'exercice délégué de l'autorité parentale 481
Sous-section 2. La procédure d'organisation 484
§ 1. Organisation conventionnelle 484
§ 2. Organisation judiciaire 485
Chapitre 2. La mission d'autorité parentale 491
Section 1. Contenu de l'autorité parentale 491
Section 2. Contrôle et limitation de l'autorité parentale 495
§ 1. Remise provisoire de l'enfant à un tiers 496
§ 2. L'assistance éducative 497
Titre 2. L'entretien matériel de l'enfant 503
Chapitre 1. Le devoir d'entretien des parents 505
Chapitre 2. L'administration et la jouissance des biens des enfants 511
Chapitre 3. L'action à fins de subsides 515

TROISIÈME PARTIE. LA SOLIDARITÉ FAMILIALE 519

Chapitre 1. La solidarité par le nom : le nom de famille 521

Section 1. L'attribution initiale du nom 523

Section 2. Le changement de nom 526

§ 1. Changements consécutifs à une modification d'état civil 528

§ 2. Changement de nom sans modification de l'état 529

§ 3. Changement de prénom 529

Chapitre 2. La solidarité par l'entraide : l'obligation alimentaire 531

Section 1. La vocation aux aliments 531

§ 1. Le cercle de solidarité familiale 532

§ 2. Déchéance exceptionnelle de la vocation aux aliments 534

Section 2. Mise en œuvre : la pension alimentaire 535

§ 1. Fixation de la pension alimentaire 536

§ 2. Régime juridique de l'obligation alimentaire 540

§ 3. Paiement de la pension alimentaire 542

§ 4. Sanctions de l'obligation alimentaire 545

Index alphabétique 553

INTRODUCTION

1 **Définition.** La famille, notion dont chacun connaît intuitivement le contenu, se définit en droit comme un groupe de personnes qui sont reliées entre elles par des liens fondés sur **l'alliance** et la **parenté** : dans la conception traditionnelle, elle repose donc sur le **mariage** et la **filiation** et la simple affection, même avec vie commune, n'y suffit pas. Mais cette conception traditionnelle est aujourd'hui battue en brèche : ainsi voit-on apparaître aujourd'hui une question nouvelle, issue des bouleversements récents : le lien créé par le PACS est-il un lien de nature familiale ? Il ne s'agit pas de pure terminologie car des conséquences juridiques sont en jeu (par exemple la protection de la vie familiale assurée par la Convention européenne des droits de l'homme). La réponse affirmative donnée progressivement par la jurisprudence (cf. *infra*, n° 417) montre d'emblée la profondeur des mutations en cours qui caractérisent la matière : les contours et la notion même de famille sont désormais moins rigides.

La famille est une réalité sociologique, économique et juridique.

2 **Aspect sociologique.** Du point de vue *sociologique*, l'unité que forme la famille se rencontre dans toutes les formes de vie sociale. Même si, au fur et à mesure de l'évolution des sociétés, ce groupe est moins structuré parce que moins vital, l'intensité du lien demeure. Le regroupement en tribus ou en familles est un phénomène constant dans toutes les sociétés primitives. Lorsque les sociétés évoluent, et que l'autorité de l'État intervient pour prendre en charge la sécurité des individus, de sorte que l'autodéfense facilitée par le regroupement est moins nécessaire, on assiste à une ***dissémination du groupe familial***. Le lien n'en demeure pas moins très fort, même s'il se traduit de manière différente. Et même dans des sociétés évoluées comme nos sociétés occidentales modernes, l'importance de la famille dans la vie sociale demeure considérable.

3 **Aspect économique.** Du point de vue *économique*, la famille constitue également une cellule fondamentale. Elle est, en effet, constitutive d'une ***unité de production*** (de richesses ou d'économies).

Ce que l'individu isolé pourrait difficilement faire seul, le groupe familial le peut de manière beaucoup plus efficace. Ici encore, cette vérité, incontestablement

de première importance dans les sociétés primitives, tend à s'affaiblir dans les sociétés évoluées. Il ne faut cependant pas croire qu'elle disparaît totalement[1]. Même dans notre société actuelle, l'unité économique que représente la famille en tant que cellule de mise en commun de ressources est loin d'être négligeable et les « dynasties » sont dans le monde éco-capitaliste une réalité incontestable : l'un des axes de la réforme des successions en 2006 a d'ailleurs été de faciliter la transmission (familiale) des entreprises. Sans doute le phénomène est-il de moindre importance lorsque l'on se trouve en présence de professions salariées en cours d'exercice. Mais une fois la retraite venue, ainsi que pour l'exercice d'une profession commerciale, artisanale, libérale, et surtout agricole, l'***entraide familiale*** demeure un fait sociologique de première importance. La collaboration du conjoint surtout, mais également parfois des enfants et des descendants, à l'unité de production, est un fait constant. Il faut y ajouter, dans tous les groupes sociaux, les aides en nature de toutes sortes qui s'y prodiguent (logement, éducation des enfants, loisirs, etc.) et qui constituent autant de *« services »* économiquement appréciables. Les périodes de difficultés économiques font régulièrement resurgir l'importance du phénomène tant il devient alors sensible qu'il est moins onéreux de vivre en groupe qu'isolé (charge des loyers par exemple) : nul n'ignore qu'un des problèmes du divorce est qu'il paupérise souvent chacun des deux époux.

4 **Aspect juridique.** Du point de vue *juridique*, enfin, l'existence de la famille est universellement reconnue et produit maints effets. Cependant, la reconnaissance du groupe familial n'a jamais été jusqu'à lui conférer la ***personnalité morale***. Bien que les relations au sein de ce groupe, notamment sur le plan matrimonial, fassent l'objet d'une organisation très précise et qu'à beaucoup d'égards la famille soit traitée comme une entité (par exemple du point de vue fiscal ou du point de vue social), notre droit ne lui reconnaît pas une personnalité juridique autonome. On remarque d'ailleurs que cette position n'est pas isolée et que les droits voisins ne reconnaissent pas non plus à la famille une telle personnalité[2]. Le principal obstacle vient de la composition trop mouvante de la famille, qui rend difficile l'identification précise de ses limites et par conséquent de ses membres[3]. Cela n'empêche pas qu'en certains domaines particuliers, on rencontre une sorte d'ébauche de propriété familiale (par exemple pour les souvenirs de famille : v. *infra*, nº 694).

§ 1. LE LIEN FAMILIAL

5 **Double nature du lien familial.** Le lien familial peut être d'une double nature : il peut résulter soit du *mariage* ou des formes d'union s'en

1. Le Guidec, Regards sur les fonctions économiques de la famille, *Mél*. Hauser, Dalloz, 2012, p. 300. – Lecaillon, *La famille, source de prospérité*, éd. Regnier, 1995.

2. En faveur d'une telle reconnaissance, v. R. Savatier, *D.* 1939, chron. 49. – Reynaud-Chanon, *D.* 1987, chron. 264.

3. Ainsi la notion de « membres de la famille » est trop floue pour fournir la base d'un texte pénal : a été déclaré contraire à la Constitution le texte qui qualifie d'« *incestueuses* » les agressions sexuelles commises par les membres de la famille (Cons. const., 16 sept. 2011, nº 2011-163 QPC ; *JCP* 2011.1160, note Lepage).

rapprochant (PACS, voire concubinage), soit de la *filiation*, c'est-à-dire d'un lien du sang. On dénomme *parenté* le lien issu du sang, tandis qu'on dénomme *alliance* le lien issu du mariage ou, à un moindre degré, du PACS.

6 **Le lien de parenté.** La parenté elle-même s'est longtemps colorée d'une qualification différente selon la nature du lien de filiation qui l'a fait naître : on parlait de *parenté légitime* en présence de personnes reliées par un lien de filiation légitime (c'est-à-dire rattaché à un mariage), de *parenté naturelle* en présence de personnes reliées par un lien de filiation naturelle (c'est-à-dire non rattaché à un mariage), de *parenté adoptive* en présence de personnes reliées par un lien de filiation adoptive (c'est-à-dire entièrement artificielle). Et si la réforme du 4 janvier 2005 a fait disparaître la distinction entre parentés légitime et naturelle, il reste celle entre la parenté biologique et la parenté adoptive (*infra*, n°s 492 et s.).

Cette parenté se divise en une parenté en ligne directe et une parenté en ligne collatérale.

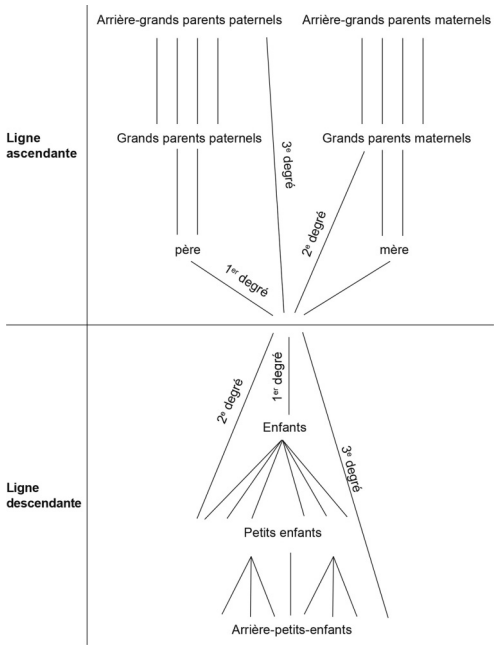
7 **Ligne directe.** La parenté en ligne directe relie les descendants aux ascendants.

La ligne descendante ne pose aucun problème : elle est constituée des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.

On calcule le ***degré de parenté*** en comptant le nombre de générations séparant les deux intéressés (art. 741). Par exemple, un père et un fils sont parents au premier degré, un grand-père et un petit-fils sont parents au deuxième degré, un arrière-grand-père et un arrière-petit-fils sont parents au troisième degré.

En ***ligne ascendante***, la parenté se divise, ce qui donnera lieu, notamment en droit successoral, à l'institution que l'on appelle la fente (art. 746 : *« la parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère »*). Il y a une ligne directe *ascendante paternelle* et une ligne directe *ascendante maternelle*. Au sein de chacune de ces lignes, le ***degré de parenté*** se calcule de la même manière que dans la ligne descendante.

TABLEAU DE LA PARENTÉ EN LIGNE DIRECTE



8 **Ligne collatérale.** La parenté *en ligne collatérale* est celle qui unit des personnes qui ont un ***auteur commun***. L'exemple le plus simple est celui des *frères et sœurs* : ils ont en commun leurs parents et sont donc des parents collatéraux. Il en est de même des oncles et neveux, des cousins, etc.

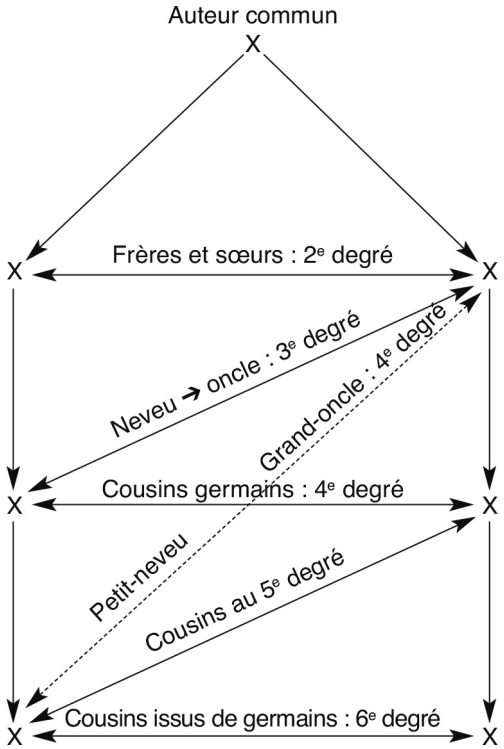
Cette parenté en ligne collatérale peut se trouver dans la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle (oncle paternel ou maternel, etc.) ou encore dans les deux lignes à la fois. Entre frères et sœurs, par exemple, il peut y avoir un lien dans les deux lignes, s'ils ont les deux parents en commun : on les dénommera **frères et sœurs *germains***.

Il peut y avoir un lien du *côté paternel* seulement si ce sont des demi-frères par leur père : on les dénommera **frères et sœurs *consanguins***.

Il peut y avoir un lien du *côté maternel* seulement si ce sont des demi-frères par leur mère : on les dénommera **frères et sœurs *utérins***.

Le calcul du *degré de parenté* en ligne collatérale s'effectue en additionnant le nombre de générations séparant chacun des intéressés de l'auteur commun (art. 743). Par exemple, entre frères et sœurs, le degré de parenté est le deuxième : une génération pour remonter du premier frère aux parents communs, une deuxième génération pour redescendre des parents communs au deuxième frère.

Tableau de la parenté en ligne collatérale



Le calcul de ce degré de parenté a une incidence notamment en ***droit successoral*** : on signalera, dès maintenant, que la vocation successorale va jusqu'au sixième degré. Il est beaucoup plus rare d'attacher des effets à la parenté en général, sans limite de degré (v. toutefois art. 449 et 456 pour le tuteur et le conseil de famille).

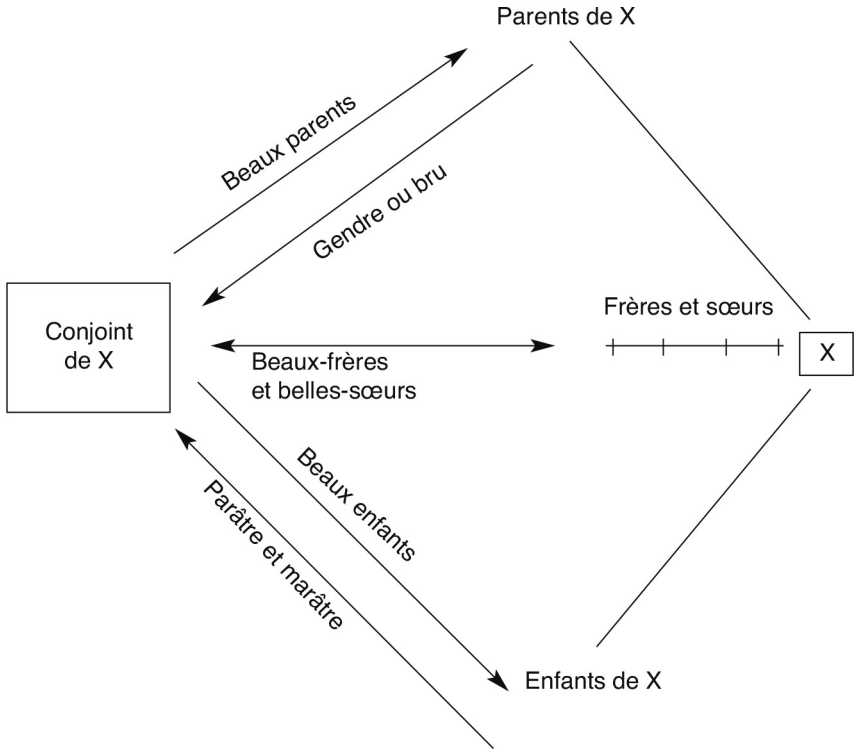
9 **Lien d'alliance.** *Le lien d'alliance* qui s'oppose au lien de parenté est celui issu d'un **mariage** (mais ni le PACS ni le concubinage ne peuvent créer de lien juridique d'alliance, en ce sens qu'ils se limitent aux intéressés sans s'étendre à leurs familles respectives). Ce mariage fait naître, bien entendu, au premier chef, un lien d'alliance *entre les époux*. Mais le lien d'alliance ne se limite pas là : le mariage fait également naître un lien d'alliance *entre chacun des époux et la parenté de l'autre*. C'est pourquoi le lien d'alliance existe également en ligne directe ou en ligne collatérale.

En ligne directe, il existe un lien d'alliance entre chaque époux et les parents de l'autre. Ceux-ci deviennent les ***beaux-parents*** de leur ***gendre*** ou de leur ***bru*** (souvent appelés aussi beau-fils et belle-fille).

Il existe également un lien d'alliance entre chaque époux et les enfants que l'autre peut avoir déjà d'une précédente union : le nouveau conjoint devient le ***parâtre*** ou la ***marâtre*** de ses ***beaux-enfants*** (le langage courant emploie plutôt les termes

de *« beau-père »* et *« belle-mère »*, même s'ils font confusion avec les parents du conjoint).

Tableau des liens d'alliance



En ligne collatérale, les frères et sœurs de chaque époux deviennent les ***beaux-frères*** et ***belles-sœurs*** du conjoint.

Le lien d'alliance se limite aux rapports de chaque époux avec la parenté de l'autre. Le mariage ne crée pas de liens généraux entre les deux familles, c'est-à-dire entre les parents d'un époux et les parents de l'autre. Ainsi les parents des deux époux, ou les frères des deux époux, n'ont aucun lien entre eux (faux beaux-frères), ce qui entraîne que, dans les *« familles recomposées »*, il n'existe aucun lien d'alliance entre les enfants *« personnels »* de chacun des deux époux.

§ 2. LE CERCLE FAMILIAL

10 **Double conception générale.** Ces deux fondements du lien familial, parenté et alliance, donnent naissance à *deux conceptions différentes* de la famille en général, selon la priorité que l'on donne à l'un ou à l'autre. *Si l'on*

donne le pas au lien de parenté, on se trouvera en présence d'une conception de la famille dite *lignage* ou *souche* (la *gens* du droit romain), cercle assez étendu. *Si l'on donne, au contraire, le pas au lien d'alliance*, on se trouvera en présence d'une conception de la *famille-foyer* (la *domus* du droit romain), cercle plus restreint.

L'évolution des civilisations démontre que l'on tend généralement à passer progressivement d'une conception de la famille-souche à la famille-foyer.

Ainsi, à **Rome**, la *gens*, tout d'abord, était le premier cadre familial, où même les enfants majeurs et leurs conjoints demeuraient placés sous la puissance du *pater familias*. Mais, au fur et à mesure de l'évolution du droit romain, l'on a assisté à un phénomène de rétrécissement de la famille et, sous l'Empire, c'est la conception de la famille-*domus* qui l'emportait.

La même évolution s'est retrouvée dans notre droit français. **L'Ancien Droit** faisait en effet incontestablement prédominer *le lignage* sur le foyer. Cela se marquait tout spécialement dans le droit des successions, où le conjoint n'avait que des prérogatives très limitées, n'ayant aucune vocation à la succession immobilière et n'ayant vocation sur les successions mobilières qu'à un usufruit (appelé *douaire* jouant le plus souvent au profit des veuves **douairières**). Le *Code civil*, dans sa rédaction primitive, était fortement inspiré de l'Ancien Droit et traduisait encore une conception de la famille-souche. Par exemple, un enfant, même majeur, ne pouvait se marier sans requérir le consentement, ou du moins l'avis (selon son âge) de ses parents. C'est au cours du XXe siècle que le renversement de conception s'est totalement marqué. On a assisté à un phénomène de ***rétrécissement de la famille*** qui s'est traduit par un *dépérissement des conséquences juridiques du lignage au profit d'un renforcement du foyer*[4].

11 **Évolution : dépérissement du lignage au profit du foyer.** Le *dépérissement des liens du lignage* s'est marqué essentiellement dans les mœurs, avant d'être consacré juridiquement. On peut en citer comme exemples le fait que les collatéraux n'ont aucune prérogative sur le plan personnel, aucune obligation, ni aucun droit alimentaire (le droit français étant ici beaucoup plus restrictif que nombre de droits étrangers), que les ascendants n'ont qu'un rôle subsidiaire par rapport au conjoint (par exemple pour être désigné en qualité de tuteur d'un conjoint incapable majeur). Sur le plan patrimonial, les collatéraux peuvent être écartés de la succession par des dispositions testamentaires et, en toute occurrence, les tarifs fiscaux les déshéritent substantiellement (aux alentours de la moitié) au profit de la collectivité nationale.

Parallèlement à ce dépérissement du lignage, s'est manifesté *un renforcement du foyer*. Le groupe qui constitue aujourd'hui la véritable famille est celui constitué par les époux et leurs enfants vivant au foyer. Toute une série de dispositions sont venues renforcer la place du conjoint dans les relations familiales.

Les institutions sociales, la protection du logement et des biens familiaux ont marqué cette prédominance du foyer seul concerné par la *« politique de la famille »*

4. Sur cette évolution, v. surtout J. Carbonnier, *Cinquante années de transformation de la famille française*, Flexible Droit, LGDJ, 1983, p. 125 (texte non repris dans les éditions ultérieures). Et, de manière plus générale, Lefebvre-Teillard, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, PUF, 1996. – Levy et Castaldo, *Histoire du droit civil*, Dalloz, 2002, n°s 57 à 83.

faite de multiples aides sociales. Sur le plan successoral, une série de réformes a amélioré la situation du conjoint survivant, tout particulièrement les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006.

Plus récemment, la nécessité d'un mariage juridique s'est estompée et le foyer se conçoit aujourd'hui autant formé de partenaires ou concubins que d'époux.

On peut donc dire que l'évolution récente du droit de la famille a été de *concentrer* celui-ci sur le foyer.

Il est parfois même proposé d'aller plus loin : l'idée de **famille *« monoparentale »*** se développe aujourd'hui avec l'accroissement à la fois des divorces sans remariage et des maternités sans mariage. La famille se réduit alors à l'extrême : un seul parent et, souvent, un seul enfant.

En outre, sa composition sociologique connait une souplesse croissante et l'on voit se dégager une notion de « famille recomposée », sorte de combiné entre le modèle classique qui demeure attrayant et les impératifs de la liberté de rejeter des liens, serait-ce pour en créer d'autres[5].

Non sans un certain paradoxe, cette évolution qui fait du foyer, même variable, le centre de la vie quotidienne, protège par contrecoup la famille par le sang : car la facilité croissante à rompre le lien d'alliance (par divorce ou rupture du PACS) emporte que celui-ci est devenu plus fragile et moins durable que le lien de parenté : de ce point de vue, la famille-souche demeure ou redevient fondamentale au bénéfice d'une permanence plus assurée.

12 **Relâchement du lien et de la hiérarchie et promotion de la liberté individuelle.** Mais cette évolution s'est accompagnée ou, plus exactement, s'est trouvée relayée, depuis un demi-siècle, par un second phénomène social qui est celui du *relâchement du lien familial au bénéfice de l'idée de liberté individuelle*.

Pendant longtemps, la famille a été conçue comme une sorte d'unité militaire participant à l'organisation sociale générale, et organisée autour d'une structure marquée par un lien de hiérarchie puissant entre les mains du père de famille, maître à la fois de son épouse[6] et de ses enfants. Mais, depuis le milieu du XXe siècle, on a vu se former un droit de la personne humaine et apparaître un fort mouvement tendant au respect et à la consécration des différentes libertés individuelles. La solidarité patrimoniale étant assurée par les institutions étatiques, le lien personnel peut se relâcher et chaque individu prendre, sur le plan de sa personne, plus d'autonomie.

C'est pourquoi l'évolution contemporaine est celle de l'affirmation de l'*autonomie des individus* au sein de la famille qui ne peut s'effectuer qu'au détriment de la force du lien familial.

L'évolution individualiste suivie par notre droit des personnes a entraîné que la liberté de chacun des membres de la famille est de mieux en mieux protégée contre les atteintes que pourraient lui porter le lien et la hiérarchie de la famille, lesquels sortent naturellement diminués de cette évolution des choses. Si l'on pouvait déjà écrire en 1950 que *« l'histoire de notre droit civil du mariage depuis cinquante ans*

5. V. Sauve, *Familles recomposées en droit successoral anglais*, *RIDC* 2019.747.

6. J. Portemer, *La femme dans la législation royale des deux derniers siècles de l'Ancien Régime* in *Mél. Petot*, Dalloz, 1959, p. 441.

est l'histoire d'une libération continue »[7], on peut dire aujourd'hui que c'est toute l'histoire du XXe siècle.

Cette évolution s'est marquée par le remplacement progressif de la hiérarchie par une égalité et une indépendance, tout particulièrement au sein du couple marié. Le mariage, comme on le verra en l'étudiant, ne fait plus naître l'ancien lien de hiérarchie caractérisé par la puissance maritale et la prédominance d'un chef de famille. La notion même de chef de famille a été abolie de notre droit civil par la loi du 4 juin 1970 (en 1982 seulement par le droit fiscal) et le mariage ne fait naître que des droits et obligations réciproques entre deux époux considérés sur un pied de stricte égalité aujourd'hui placé sous la protection de la Convention européenne des droits de l'homme[8].

Quant aux liens, leur relâchement a permis une plus grande liberté de chacun. Il en résulte que le lien matrimonial est de moins en moins contraignant, ce qui se traduit, par exemple, par un accroissement de l'autonomie et de l'indépendance de chaque époux pendant le mariage, ainsi que par une plus grande facilité pour chaque époux de se libérer de ce lien par un divorce.

Au-delà de la hiérarchie, c'est l'idée même **d'engagement** qui s'est trouvée atteinte : même égalitaire, le mariage crée un lien juridique que la poussée de l'individualisme rejette souvent. C'est ce qui explique l'accroissement spectaculaire, depuis les années 1970, de l'union libre, puis l'instauration du PACS librement résiliable, et l'admission de véritables familles ou foyers sans mariage.

De même, l'abaissement de l'âge de la majorité est une manière de réduire au minimum la période pendant laquelle les enfants sont soumis à l'autorité parentale. On a pu écrire que le droit de la famille est devenu un droit *« individualiste, libérateur et émancipateur »*, recherchant le bonheur de l'individu *« contre le groupe, contre le caractère indissoluble et sacré des liens et de la hiérarchie »* et en fin de compte un droit *« anti-familial »*[9] et, dès 1984, le Conseil économique et social a relevé les *« évolutions sans précédent qui ont marqué la démographie des ménages au cours de la dernière décennie »*, constatant l'abandon ou l'affaiblissement des *« principes du respect de la hiérarchie patriarcale, du respect de l'institution, de la force de la légitimité en matière de filiation et de succession, de l'engagement personnel solennel au profit d'une promotion des principes de la liberté personnelle, du respect de l'intérêt particulier de chacun des membres du couple en tant qu'individu, de l'égalité entre les membres du couple pendant le mariage dans leurs relations réciproques et dans leurs responsabilités et prérogatives à l'endroit de leurs enfants, de l'équité entre enfants naturels, adoptifs et légitimes »*. Le mouvement n'a fait que se renforcer pour aboutir à la véritable refondation du droit de la famille au début du XXIe siècle (*infra*, nº 15).

7. Carbonnier, *Terre et ciel dans le droit français du mariage* in *Mél. Ripert*, Dalloz, 1950, p. 328.

8. Au point qu'une loi étrangère contraire ne peut recevoir application en France : Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, *Bull. civ.* I, nº 71 (pour une ancienne loi suisse donnant une priorité au mari sur certains droits patrimoniaux). – V. aussi pour les ruptures réservées au seul mari : Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, nº 08-20574 ; *Bull. civ.* I, nº 217. – Cass. 1re civ., 23 nov. 2013, nos 12-25802 et 12-21344.

9. E. du Pontavice, *Droit au bonheur et droit de la famille* in *Mél. Voirin*, LGDJ, 1967, p. 678.

Certains y ont vu une crise de la famille[10] mais toute évolution n'est pas crise : la famille vit différemment entre individus égaux et dégagée de la pression sociale, mais elle n'en est pas moins vivante pour autant.

L'individualisme peut aboutir à une satellisation extrême des cellules familiales : les *« familles monoparentales »* (où l'enfant est élevé par un seul parent à la suite d'un divorce ou par défaut de tout mariage) sont en nombre croissant, tout spécialement en milieu urbain.

Or ces phénomènes sont extrêmement importants, car le droit ne fait, en réalité, que suivre dans ces matières l'évolution des mœurs. C'est d'ailleurs l'un des traits fondamentaux du droit de la famille que cette dépendance de l'état des mœurs.

§ 3. LE DROIT FAMILIAL

13 **Originalité du droit de la famille.** Le droit de la famille présente, bien qu'il soit incontestablement une discipline appartenant au droit civil, une certaine originalité et une certaine autonomie au sein de celui-ci[11] qui se traduit notamment par un foisonnement de publications et revues spécifiques[12]. Ses traits particuliers se marquent tout à la fois dans son fondement, dans son évolution et dans son application.

14 **Quant à son fondement.** Quant au *fondement* du droit de la famille, il résulte essentiellement de l'état sociologique de la population à régir. Plus que toute autre branche juridique, ce droit est *dépendant des bouleversements sociologiques*. Il est directement influencé par les **conceptions morales**, ainsi que par les conceptions **religieuses** qui sont en vigueur dans une population à un moment donné. Il ne faut pas oublier à cet égard que, sous l'Ancien Droit, le droit de la famille ne dépendait pas de l'autorité publique mais de l'autorité ecclésiastique, de sorte qu'il se confondait purement et simplement avec la doctrine religieuse en la matière et qu'il en va encore ainsi dans de nombreux pays (notamment musulmans).

Si la séparation de l'Église et de l'État, puis la distorsion des conceptions religieuses et des conceptions sociologiques ont rompu ce lien, certaines traces importantes en subsistent[13].

15 **Quant à son évolution contemporaine.** L'évolution qu'a subie le droit de la famille au cours du dernier demi-siècle est d'ailleurs caractéristique de cette dépendance vis-à-vis de l'état des mœurs de la population.

10. E. DE LAGRANGE, *La crise de la famille* in *Mél. Weill*, Dalloz, 1983, p. 353.

11. Sur cette originalité, v. E. du PONTAVICE, *L'autonomie du droit de la famille*, 1974 ; Archives philosophiques du droit 1975. – H. GAUDEMET-TALLON, *De quelques paradoxes en matière de droit de la famille*, *RTD civ.* 1981.719. – HAUSER, *Grandeur et décadence du droit de la famille à la fin du XXe siècle* in *Mél. Huet-Weiller*, Dalloz, 1996, 235.

12. V. la bibliographie, *infra*, nº 22.

13. V. DEKEUWER-DEFOSSEZ, *Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille, RTD civ.* 1995, 249 et *Modèles et normes en droit contemporain de la famille* in *Mél. Mouly*, 1998, 281 et s.

C'est, en effet, une constatation sociologique que l'importante évolution de l'état des mœurs en Occident depuis les années 1950-1960. Et l'on remarque que le droit de la famille a partout subi un bouleversement total depuis un demi-siècle. En France, aucune autre partie du droit civil n'a été aussi profondément remaniée que le droit de la famille. C'est au point qu'à l'heure actuelle il ne subsiste à peu près rien non seulement du Code civil initial, mais même du droit positif des années 1960.

Dans ce bouleversement total, on peut distinguer trois phases.

— ***La première*** est celle d'une **refondation** que l'on peut appeler la « *rénovation Carbonnier* », du nom de l'auteur de la plupart des projets ayant abouti aux lois concernées. Ainsi une loi du 14 décembre 1964 a remanié la matière du droit des *tutelles des mineurs* ; une loi du 13 juillet 1965 a refondu le régime *des rapports patrimoniaux entre les époux* ; une loi du 11 juillet 1966 a réformé *l'adoption* ; une loi du 4 juin 1970 a remplacé la puissance paternelle par *l'autorité parentale* qu'elle a organisée ; une loi fondamentale du 3 juillet 1972 a entièrement transformé *le droit de la filiation* ; une loi du 5 juillet 1974 a abaissé l'âge *de la majorité* à 18 ans ; une loi du 11 juillet 1975 a entièrement modifié *le droit du divorce*.

— ***La deuxième phase*** a été celle des **retouches** apportées aux réformes (dites parfois « *toilettages* ») : une loi du 22 juin 1982 a modifié, sur un point précis mais de portée considérable, l'établissement de la **filiation naturelle**, tandis qu'une loi du 10 juillet suivant organisait la collaboration professionnelle entre époux dans les professions commerciales, artisanales et libérales ; une loi du 23 décembre 1985 est venue achever l'égalité entre les époux dans le domaine patrimonial, tant en ce qui touche leurs biens que l'administration de ceux de leurs enfants ; une loi du 22 juillet 1987 a adapté le droit de l'**autorité parentale** au développement des divorces (en organisant la « *garde conjointe* ») et des concubinages (en facilitant l'éducation en commun des enfants naturels) ; une loi du 8 janvier 1993 a retouché de multiples points, à la fois quant à l'**autorité parentale** (sur les enfants naturels), quant à la **filiation** (**naturelle**) et, plus profondément à terme, quant à la **juridiction familiale** (création du juge aux affaires familiales). Une loi du 5 juillet 1996 a retouché (plus que réformé) le droit de l'**adoption** et une loi du 30 juin 2000 a modifié la prestation compensatoire après divorce.

— ***La troisième phase*** est celle que nous vivons à l'heure actuelle et que l'on pourrait appeler celle de la **révolution du XXIe siècle**. C'était une erreur de penser que le nouvel état issu de la refondation précédente s'installerait dans la stabilité. Les mouvements tectoniques de la société se sont poursuivis et le changement de siècle s'est marqué par de nouvelles transformations, souvent plus radicales que les précédentes : institution du PACS (loi du 15 novembre 1999, refondue par celle du 23 juin 2006) ; réforme du droit des successions (loi du 23 juin 2006 précédée de celle du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant) ; refonte du droit de l'autorité parentale (loi du 4 mars 2002 et ordonnance du 15 octobre 2015) ; instauration d'un régime du nom de famille (autre loi du 4 mars 2002 puis du 4 juillet 2005) ; réforme du divorce (lois du 26 mai 2004, du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019) ; transformation totale du droit de la filiation (d'abord par les lois « *bioéthique* » du 29 juillet 1994 et 6 août 2004, et ensuite et surtout